

1501854-61.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: KLEBER LELES DE SOUZA

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2258111/2021 - DISE-

DEL.SEC.DIADEMA, 20391852 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA, 86/21/301 - DISE-

DEL.SEC.DIADEMA, 2258111 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501854-61.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501854-61.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2258111/2021 - DISE-

DEL.SEC.DIADEMA, 20391852 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA, 86/21/301 - DISE-

DEL.SEC.DIADEMA, 2258111 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENO SANTOS SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). KLEBER LELES DE SOUZA

Vistos,

BRENO SANTOS SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, conforme a denúncia, no dia 21/09/2021, o acusado trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 28 (vinte e oito) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso aproximado de 18 gramas, 25 (vinte e cinco) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso aproximado de 27 gramas e 06 (seis) frascos contendo cloreto de etila vulgarmente conhecido como "lança perfume", com volume aproximado de 268 mililitros, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 21/22, laudo de constatação provisória de fls. 26/28 e laudo de exame químico

toxicológico de fls. 67/69.

Segundo a acusação, no dia dos fatos, policiais civis realizavam diligências com viatura descaracterizada em conhecido ponto de venda de drogas, oportunidade em que visualizaram o denunciado em atitude suspeita, com comportamento nervoso, motivo pelo qual o abordaram. Em revista pessoal, os policiais localizaram com o denunciado duas porções de maconha. Indagado, o denunciado admitiu a traficância e indicou onde estava guardado o restante das drogas que seriam comercializadas. No local apontado, embaixo de uma escada próxima, os policiais encontraram uma sacola contendo 28 porções de cocaína, 23 de maconha e 06 frascos de lança perfume. Em solo policial, o denunciado tornou a confessar o crime e esclareceu, inclusive, o horário que realizava a atividade, quanto ganharia pela atividade e por quanto venderia as drogas (fls. 04). Neste contexto, de acordo com a denúncia, a finalidade do tráfico restou devidamente demonstrada pela natureza e quantidade das drogas, pela forma do acondicionamento, assim como, pelo local dos fatos e pelas condições em que se desenvolveu a ação.

O réu foi regularmente notificado (fls. 93), tendo apresentado defesa preliminar a fls. 97/98. A denúncia foi recebida a fls. 105/106, e o réu foi regularmente citado (fls. 127).

Na audiência de instrução debates e julgamento foi colhida a prova oral. Ao final, as partes se manifestaram em debates orais, o que foi registrado pelo sistema de gravação de áudio e vídeo, nos termos do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não havendo preliminares a serem apreciadas, pelo mérito a presente ação penal é PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo laudo pericial de fls. 67/69, que atestou positivo para as substâncias entorpecentes tetrahidrocanabiol (THC - maconha) e cocaína, substâncias estas consideradas ilícitas pela Portaria 344/1998 SVS/MS. Consigno que a perícia não foi contestada pela defesa.

A autoria também restou devidamente comprova nos autos, tanto pelas provas colhidas durante a fase de investigação policial, quanto pelas provas produzidas em juízo. É certo que de acordo com o art. 155, do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso dos autos, estes elementos informativos da investigação foram corroborados pela prova produzida em contraditório.

Em sede policial, os policiais civis responsáveis pela prisão do acusado afirmaram, em resumo, que com o objetivo de coibir o tráfico de drogas, diligenciaram com uma viatura descaracterizada até a Passagem dos Sonhos, próximo ao número 8, Jardim Inamar, Diadema/SP, conhecido local de traficância de drogas, e ao se aproximarem do local onde costuma ficar o "vapor" (pessoa responsável por vender a droga), visualizaram um indivíduo de blusa azul e preta parado no local, demonstrando certo nervosismo, olhando de um lado para o outro e então decidiram por abordá-lo.

Relataram que efetuada a abordagem, o identificaram como sendo BRENO SANTOS SOUZA, em busca pessoal foram localizados dois invólucros de maconha; quando questionado, o indivíduo (aqui acusado) assumiu fazer a venda das drogas, indicando um pequeno saco embaixo de uma escada que dá acesso a uma casa do nível superior, onde foram localizados outros invólucros de substâncias assemelhadas a maconha, cocaína e lança perfume, sendo então imediatamente exarada voz de prisão ao mesmo pelo crime de tráfico de drogas e junto das substâncias foi conduzido até a unidade e apresentado à autoridade policial.

Em juízo, a testemunha WILLIAM DIVETTA CARRIERI confirmou integralmente a dinâmica contida na denúncia. Disse que não conhecia o réu anteriormente, não se recordando de tê-lo abordado. Disse que não foi apreendido dinheiro com o réu. Com ele, em revista pessoal, foram encontradas duas porções de maconha, e o próprio acusado mostrou aos policiais onde estavam as demais drogas.

A testemunha ADRIANO MOREIRA PONTE, ouvido em juízo, confirmou o depoimento de seu parceiro, acrescentando que as drogas estavam em embaixo de uma escada, cerca de dois ou três metros do acusado.

Observe-se que os depoimentos prestados em juízo por estes policiais, além de

plenamente coerentes, estão em perfeita harmonia àqueles por eles prestados perante a autoridade policial. Ademais, não há qualquer motivo a que não possa ser atribuído total crédito a tais depoimentos. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que os policiais tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente o réu. E, afinal, o fato de estas testemunhas serem policiais, por si só, não tem o condão de enfraquecer a prova coligida, sobretudo porque seus depoimentos estão amparados em outros elementos de convicção.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser “inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372). E ainda: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC n.º 74.608-SP – STF).

Deve-se ressaltar que o réu, em seu interrogatório prestado perante a autoridade policial, confessou o delito. Afirmou que reside com a sua genitora e dois irmãos e que sua mãe ficou desempregada, razão pela qual havia duas semanas que aceitara vender drogas no local. Declarou que tem ficado naquele local das 8 as 16 horas e que ao final do seu turno recebe o valor de R\$ 60,00 (sessenta reais). Declarou que vendia a unidade do invólucro de maconha pelo valor de R\$ 5,00 (cinco reais), a unidade do invólucro de cocaína pelo valor de R\$ 10,00 (dez reais) e a unidade do invólucro de lança perfume pelo valor de R\$ 5,00 (cinco reais). Declarou que chega no local (biqueira) no horário combinado, e um indivíduo desconhecido aparece e entrega um saco com as drogas e vai embora, retornando depois em horários incertos. Declarou que estava na biqueira vendendo as drogas quando foi abordado por policiais em um carro “normal” e, após localizar as drogas, disseram que estava preso e o trouxeram até esta delegacia.

Em juízo o acusado voltou a confessar o crime. Disse estar arrependido.

Ora, o local em que ocorreu a prisão (conhecido ponto de tráfico de drogas), a forma como estava embalada a droga, a quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, e a dinâmica dos fatos, apurada em observação prévia feita pelos policiais são indicativos do intuito de traficância. Por outro lado, pela própria quantidade e demais circunstâncias, não há como desclassificar a conduta para o porte de entorpecente para consumo pessoal, sendo certo que a figura do usuário não é incompatível com a do traficante, podendo coexistirem pacificamente em uma única pessoa.

Não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelo réu se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, notadamente porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (STF, 1.ª T. – HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p. 11.012).

A confissão se coaduna com os demais elementos probatórios, impondo a condenação do acusado.

Ausente qualquer excludente de tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade.

Ressalto que o argumento de que o acusado praticou o crime em razão de precariedade financeira não possui o condão de afastar sua responsabilidade penal, tampouco de reduzir a sua pena. Isto porque não se pode confundir estado de necessidade com estado de precisão.

Lamentavelmente, milhares de brasileiros passam por situação econômica desfavorável, enfrentando dificuldades para sustentar a si e seus familiares. Nem por isso se enveredam pelo caminho do crime. Ao contrário: buscam solução para seus problemas financeiros através de trabalho honesto. Sobre o tema, já se decidiu:

“Também não há que se falar em estado de necessidade, pois não há provas nos autos

de que o apelante passava por miserabilidade extrema a ponto de ter que violar e lei para sobreviver. A mera dificuldade financeira não autoriza ninguém a praticar delitos" (TJSP, Apelação Criminal n.º 0006727-87.2004.8.26.0081, Rel. Caio Ferraz de Camargo Lopasso, 5.ª Câmara Criminal D.J.E., j. em 29.07.2011). É o que basta para a caracterização do(s) delito(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 33, da Lei de Drogas.

Comprovada, assim, a autoria e a materialidade do delito. Impõe-se, nestes termos, a condenação do acusado.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, ante a pequena quantidade de drogas apreendidas e ausência de maiores informações acerca da pessoa do acusado, não vislumbro a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo diploma legislativo, considerando as condições econômicas do réu.

Na segunda fase da dosimetria, anoto a existência das atenuantes genéricas da menoridade relativa e da confissão, as quais, contudo, não poderão conduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do E. Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase da dosimetria, deve incidir a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4.º, da Lei 11.343/06. De acordo com entendimento amplamente majoritário do E. Supremo Tribunal Federal, "a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa" (HC n.º 124.107/SP, Primeira Turma, Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/11/14; HC n.º 122.626/SP, Primeira Turma, rel. Dias Toffoli, DJe de 17/11/14; RHC n.º 118.008/SP, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 19/11/13; HC n.º 108.388/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/4/13; Recurso Ordinário em HC n.º 116.049, rel. Dias Toffoli; HC n.º 111.309/DF, rel. Ministro Roberto Barroso).

No caso em tela, anoto que as circunstâncias não indicam que o acusado tenha envolvimento de forma reiterada ou profissional com a atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida. De fato, não há provas seguras de que o réu já praticava a traficância anteriormente, de modo que cabível a redução, no patamar de 2/3, levando-se em conta para a fixação deste patamar a quantidade de drogas apreendida.

Registro que a utilização deste critério (quantidade da droga apreendida) apenas na terceira fase permite um melhor equacionamento da pena e sua correta individualização, sem implicar bis in idem. Neste sentido, aliás, tem sido o posicionamento da E. 1.ª Turma do Supremo Tribunal Federal: "A quantidade de droga apreendida é fundamento idôneo para justificar o patamar de redução da pena em razão da incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º da Lei de Tóxicos. Precedentes" (STF, 1.ª T., HC n.º 110.487/RS, rel. Ministra Cármen Lúcia, j. 14/02/2012); e ainda: "A causa especial de diminuição de pena de que trata o § 4.º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 pode ser aplicada em apenas 1/6 (um sexto), num intervalo de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), com fundamento na quantidade de entorpecente, que é critério preponderante fixado na lei, revelando a justeza da sanção no caso concreto. Precedentes: HC 98.900, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/11/2010 e HC 94.559, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 04/11/2010" (STF, 1.ª T., HC n.º 104.195, rel. Min. Luiz Fux, j. 26/04/2011).

Assim, por força da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4.º, da Lei 11.343/06, reduzo a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na forma especificada. A ausência de outras circunstâncias que pudessem modificar a pena fixada, torno-a definitiva.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena, o plenário do Supremo

Tribunal Federal decidiu, quando do julgamento do habeas corpus n.º 111.840-ES (Informativo STF n.º 507), ser inconstitucional a fixação obrigatória de regime inicial fechado, consoante dispõe o § 1.º, art. 2.º, da Lei n.º 8.072/90, com as alterações decorrentes da Lei n.º 11.464/07. Assim, de acordo com referido precedente, compete ao juiz, analisadas as especificidades do caso concreto, fixar o regime inicial de cumprimento de acordo com as disposições do art. 33, do Código Penal.

Este mesmo entendimento deve ser aplicado no caso em tela, quer pela chamada "objetivação do controle difuso" (tese adotada e aplicada pelo E. Supremo Tribunal Federal), quer em sede de controle difuso de constitucionalidade por este Magistrado, declarando-se a inconstitucionalidade, incidenter tantum, do dispositivo legal em comento. De fato, a fixação a priori, pelo legislador, de um regime inicial de cumprimento, sem permitir que o Magistrado possa aferir, no caso concreto, qual o regime mais adequado para o sentenciado, com análise dos requisitos objetivos e subjetivos, fere o princípio implícito da proporcionalidade e o princípio da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5.º da CF/88). Partindo desta premissa, passo a fixar o regime inicial de cumprimento de pena. Considerando a quantidade de pena fixada (inferior a 04 anos), a primariedade do agente, bem como o tempo da prisão preventiva, fixo o regime inicial aberto, por entender, diante destas circunstâncias, ser este regime suficiente para fins de reprovação e prevenção da conduta a ele imputada.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de condenar o réu BRENO SANTOS SOUZA qualificado nos autos, à pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal, por infração ao artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06.

Fixo, desde logo, as seguintes condições para cumprimento da pena em regime aberto (art. 115, da Lei n.º 7.210/84):

- (a) permanecer em sua residência durante o repouso e nos dias de folga;
- (b) sair para apenas para tratamento médico, estudo ou trabalho, retornando ao término do expediente;
- (c) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 08 (oito) dias, sem prévia autorização judicial;
- (d) comparecimento periódico em Juízo (em prazo a ser fixado no Juízo da Execução Criminal), para informar e justificar as suas atividades.
- (e) Não frequentar determinados lugares, a saber: pontos de venda de drogas ("biqueiras"), locais e eventos em que sejam oferecidas ao público, de forma gratuita ou onerosa, bebidas alcoólicas para consumo imediato (bares, bailes, festas, "baladas" e congêneres).

Ainda, considerando os precedentes do E. Supremo Tribunal Federal em casos assemelhados, a Resolução n.º 05, do Senado Federal, bem como a presença das condições legais para tanto (art. 44, do Código Penal), SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, uma na modalidade prestação de serviços à comunidade (art. 43, inciso IV, do CP), e outra na modalidade prestação pecuniária (art. 43, inciso I, do CP), eis que a pena aplicada é superior a 01 (um) ano, na forma do artigo 44, § 2.º, do Código Penal.

A prestação de serviços à comunidade deverá ser cumprida em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos ou outros, na forma do artigo 46 do Código Penal, devendo tal local ser indicado pelo Juízo da Execução na forma do artigo 149 da LEP. As tarefas deverão ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, até que venha a totalizar a pena imposta, na forma do artigo 46, § 3.º, do Código Penal.

Já a prestação pecuniária, que fixo no mínimo legal de 01 (um) salário mínimo, consiste no pagamento de dinheiro a entidade pública ou privada de destinação social, a ser identificada pelo Juízo das Execuções Criminais.

As penas de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, que substituem a pena privativa de liberdade, são aplicadas sem prejuízo da multa cominada cumulativamente, eis que a substituição em questão somente alcança a

reprimenda corporal e não a pena de multa. Em caso de reconversão a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime aberto. Considerando a quantidade de pena aplicada e o regime inicial de seu cumprimento, bem como a ausência dos requisitos legais que autorizam a prisão preventiva, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Condene o acusado ao pagamento das custas, na forma do artigo 4.º, § 9.º, da Lei 11.608/03, ressalvada a hipótese de ser beneficiário da Assistência Judiciária. Proceda-se à destruição das drogas, na forma do art. 72, da Lei n.º 11.343/2006. Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória (Resolução 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ) para que possa postular, perante a Vara de Execuções Criminais, o que entender cabível.

Transitada em julgado:

a) expeça-se guia de execução definitiva e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime;

b) oficie-se ao IIRGD;

c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Diadema, 12 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA